



COURS DE DROIT ADMINISTRATIF : LE SERVICE PUBLIC

INTRODUCTION

Le service public constitue, avec la police administrative, l'un des deux piliers fondamentaux de l'action de l'administration et l'un des concepts les plus cardinaux du droit public. Historiquement, la notion de service public a servi de critère exclusif de définition et de délimitation du droit administratif, sous l'impulsion de l'École de Bordeaux menée par le doyen Léon Duguit. Pour cette doctrine classique, le service public est le fondement même de la légitimité de l'État : le pouvoir des gouvernants ne se justifie que par les services qu'ils rendent aux gouvernés. Bien que le droit positif contemporain ait consacré une diversification des critères du droit administratif, le service public demeure l'instrument privilégié par lequel l'État et les autres personnes morales de droit public réalisent l'intérêt général. Définir le service public exige d'adopter une démarche synthétique combinant deux critères cumulatifs : un critère matériel ou fonctionnel, qui est l'activité d'intérêt général, et un critère organique, qui est la prise en charge, directe ou indirecte, par une personne publique. L'intérêt juridique de ce thème réside dans l'étude d'un régime juridique exorbitant du droit commun, caractérisé par des lois de fonctionnement rigoureuses appelées « lois de Rolland » et par des modes de gestion diversifiés allant de la régie directe à la délégation contractuelle. Sur le plan normatif, le service public trouve son ancrage dans les préambules et textes constitutionnels garantissant les droits économiques et sociaux, ainsi que dans de nombreuses lois sectorielles et codes administratifs. Les enjeux juridiques contemporains se cristallisent autour de la confrontation entre le modèle classique du service public et le droit de la concurrence, de la crise du financement des prestations publiques, de l'impact de la numérisation sur la continuité du service et de l'exigence croissante de qualité de la part des usagers. Dès lors, la problématique centrale de ce cours se formule ainsi : comment l'ordonnancement juridique parvient-il à concilier la permanence des principes traditionnels du service public avec les mutations économiques, technologiques et conventionnelles contemporaines qui imposent une contractualisation et une ouverture à la concurrence des activités d'intérêt général ? Pour répondre à cette problématique, il conviendra d'analyser dans un premier temps les critères d'identification et la classification des services publics, d'étudier dans un deuxième temps les principes directeurs régissant leur fonctionnement, et d'examiner enfin les différents modes de gestion et de dévolution des services publics.

I. Les critères d'identification et la classification des services publics

La qualification de service public emporte l'application d'un régime juridique spécifique, ce qui impose une définition précise de ses éléments constitutifs et de ses différentes catégories.

A. Le double critère d'identification : l'intérêt général et le lien avec une personne publique

Pour qu'une activité soit qualifiée de service public, la jurisprudence administrative exige la réunion de deux éléments fondamentaux. Le premier est le critère matériel, à savoir la poursuite d'une mission d'intérêt général. L'intérêt général est une notion évolutive, définie par le législateur ou le juge, qui dépasse la simple somme des intérêts privés pour embrasser les besoins essentiels de la collectivité, tels que l'éducation, la santé, la justice, la sécurité ou la culture. Le second est le critère organique, qui implique le contrôle d'une personne publique sur l'activité. Historiquement,

le service public était directement géré par l'administration. Toutefois, l'évolution du droit a admis qu'une personne privée puisse gérer un service public. Dans cette hypothèse, la jurisprudence (notamment issue de l'arrêt du Conseil d'État français *Astre* de 1938 ou de l'arrêt *Cité de l'UEMOA*) recherche l'existence d'un faisceau de indices : la personne publique doit avoir confié explicitement la mission à l'entité privée, elle doit exercer un contrôle étroit sur sa gestion, et elle doit lui avoir octroyé, le cas échéant, des prérogatives de puissance publique (telles que le pouvoir d'expropriation, de lever des taxes ou de prendre des décisions unilatérales obligatoires).

B. La distinction fondamentale entre SPA et SPIC et ses conséquences juridiques

L'évolution de l'action administrative a brisé l'unité du régime du service public par l'émergence d'activités à caractère industriel et commercial. La jurisprudence issue de l'arrêt du Tribunal des conflits français *Société commerciale de l'Ouest africain* de 1921 (connu sous le nom d'arrêt *Bac d'Eloka*) a opéré une distinction binaire majeure entre les services publics à caractère administratif (SPA) et les services publics à caractère industriel et commercial (SPIC). Pour classer un service dans l'une ou l'autre catégorie en l'absence de qualification textuelle expresse, le juge applique trois critères cumulatifs : l'objet du service, l'origine de ses ressources et les modalités de son fonctionnement. Un service est un SPIC si son objet consiste en la production ou la vente de biens et de services analogues à ceux d'une entreprise privée, si ses ressources proviennent majoritairement des redevances payées par les usagers en contrepartie du service rendu, et si ses modalités de fonctionnement s'apparentent à celles d'une société commerciale. Cette qualification emporte des conséquences juridiques de première importance : le SPA est soumis de plein droit au droit administratif et au juge administratif, tandis que le SPIC est régi de manière prépondérante par le droit privé et le juge judiciaire, notamment dans ses relations avec ses usagers et son personnel, sous réserve du statut de son directeur général et de son comptable public.

II. Les principes directeurs du fonctionnement des services publics : les « lois de Rolland »

Quel que soit le caractère administratif ou industriel du service public, son fonctionnement repose sur un ensemble de principes fondamentaux, théorisés par le juriste Louis Rolland, qui s'imposent comme des principes généraux du droit.

A. Le principe de continuité et le principe de mutabilité

Le principe de continuité exige que le service public fonctionne de manière régulière, sans interruption injustifiée, afin de satisfaire les besoins permanents de la population. Ce principe possède une valeur constitutionnelle supérieure. Il justifie les limitations rigoureuses apportées au droit de grève des agents publics, l'administration ayant le pouvoir de réglementer la grève, d'instaurer un service minimum ou de procéder à des réquisitions de personnels indispensables à la sécurité publique. Le principe de continuité explique également la théorie jurisprudentielle de l'imprévision en matière de contrats administratifs, qui oblige l'administration à soutenir financièrement son cocontractant en cas de bouleversement économique extérieur, afin d'éviter l'arrêt du service. Le principe de mutabilité, ou d'adaptabilité, dispose que le service public doit évoluer constamment pour s'adapter aux changements de circonstances de fait, aux progrès techniques et à l'intérêt général. En vertu de ce principe, l'administration détient le pouvoir de modifier unilatéralement l'organisation du service public ou le régime juridique des contrats administratifs, sans que les usagers ou les contractants ne puissent se prévaloir d'un droit acquis au maintien du règlement antérieur.

B. Le principe d'égalité et ses corollaires : neutralité et laïcité

Le principe d'égalité devant le service public prescrit que toutes les personnes se trouvant dans une situation identique doivent être traitées de la même manière et bénéficier des mêmes prestations, sans discrimination fondée sur l'origine, le sexe, la race, la religion ou les opinions politiques. Ce principe interdit la fixation de tarifs différenciés pour l'accès au service, sauf s'il existe entre les usagers des différences de situation appréciables en rapport direct avec l'objet du service (comme des critères de ressources pour un service social), ou si la loi l'a expressément prévu. Le principe de neutralité constitue le corollaire indispensable de l'égalité : le service public doit être assuré avec une stricte impartialité, ce qui interdit aux agents publics d'utiliser leurs fonctions comme instrument de propagande politique, philosophique ou religieuse. Dans les États proclamant leur caractère laïque, à l'instar du Sénégal ou de la France, la laïcité du service public impose une obligation de stricte neutralité religieuse aux agents, qui ne peuvent arborer aucun signe manifestant leur appartenance confessionnelle dans l'exercice de leurs missions, afin de garantir la liberté de conscience de tous les usagers.

III. Les modes de gestion et de dévolution des services publics

Pour mettre en œuvre une activité de service public, les personnes publiques disposent d'un choix stratégique et juridique entre une gestion par leurs propres moyens ou une externalisation vers des entités tierces.

A. La gestion directe par la personne publique : la régie et l'établissement public

La gestion directe, ou gestion publique, se caractérise par le fait que la personne publique assure elle-même l'exécution du service avec ses propres moyens matériels, financiers et humains. La modalité la plus traditionnelle est la régie simple, dans laquelle le service est intégré organiquement au sein de l'administration (ministère, direction, secrétariat municipal) sans disposer d'aucune autonomie juridique ou financière. Le budget du service est inscrit directement au budget général de la collectivité et ses agents sont des fonctionnaires soumis à la hiérarchie. L'administration peut également recourir à la régie personnalisée, dotée d'une simple autonomie financière par l'octroi d'un budget annexe. Lorsque la complexité technique de l'activité requiert une individualisation plus poussée, la personne publique crée une structure décentralisée fonctionnellement : l'établissement public (EPA ou EPIC), analysé précédemment, qui dispose de la personnalité morale et de organes de gestion propres, mais demeure soumis à un contrôle de tutelle étroite de la part de la collectivité de rattachement.

B. La gestion déléguée ou contractuelle : les concessions et les partenariats public-privé

L'externalisation du service public s'opère par le biais des contrats de concession ou de délégation de service public (DSP). Par ces actes conventionnels, une personne publique (le délégant) confie par contrat la gestion d'un service public dont elle a la responsabilité à une personne privée ou publique (le délégataire), dont la rémunération est substantiellement liée aux résultats de l'exploitation du service, transférant ainsi un risque économique réel au gestionnaire. La concession classique implique que le concessionnaire construise les ouvrages nécessaires à ses frais et se rémunère par des redevances perçues sur les usagers du service (comme l'exploitation des autoroutes ou la distribution d'eau et d'électricité). Le droit des contrats administratifs, fortement harmonisé en Afrique par les directives de l'UEMOA et les législations nationales sur les marchés publics, encadre strictement la passation de ces contrats en imposant des règles de publicité et de mise en concurrence. Les contrats de partenariat public-privé (PPP) complètent ces dispositifs en permettant à l'administration de confier globalement au secteur privé le financement, la construction et la maintenance d'équipements publics, la rémunération étant

versée par l'administration sous forme de loyers étalés dans le temps, illustrant la managérialisation contemporaine du droit du service public.

CONCLUSION

Le service public demeure une notion dynamique et indispensable à la cohésion sociale et au développement économique des nations. Si ses principes cardinaux de continuité, d'égalité et de mutabilité conservent toute leur valeur normative et jurisprudentielle, leurs modalités de mise en œuvre ont profondément muté sous l'effet du droit international, des règles de concurrence et de l'introduction de critères d'efficience managériale. Le juge administratif joue un rôle de régulateur essentiel en veillant à ce que l'introduction des logiques de marché et la privatisation de la gestion n'altèrent pas la substance de la mission d'intérêt général ni les droits fondamentaux des usagers. Le défi majeur des systèmes juridiques contemporains, notamment en Afrique, réside dans l'édification d'un droit du service public capable de garantir l'accès universel aux prestations essentielles (eau, énergie, éducation, santé) tout en sécurisant les investissements privés indispensables à la modernisation des infrastructures.